

1500849-73.2021.8.26.0417

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... criminosa e condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11343/06.

A defesa de MARCELO BRANDÃO LEITE requereu a absolvição do crime de tráfico de drogas, a luz da dicção do artigo 386, III, da legislação adjetiva penal e a absolvição com relação ao delito de associação. Ademais pugnou pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

1ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500849-73.2021.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500849-73.2021.8.26.0417

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2264055/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PARAGUAÇU PTA, 20511889 - DEL.POL.PLANTÃO PARAGUAÇU PTA, 239/21/508 - DEL.POL.PLANTÃO PARAGUAÇU PTA, 2264055 - DEL.POL.PLANTÃO PARAGUAÇU PTA, 2264055/2021 - Delegacia de Polícia de Paraguaçu Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO BRANDÃO LEITE e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Vistos.

MARCELO BRANDÃO LEITE e VICENTE JÚNIOR DA CRUZ, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V e 35, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque , em data incerta, porém compreendendo período anterior ao dia 27 de setembro de 2021, nesta cidade e comarca de Paraguaçu Paulista, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas.

A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2022, bem como indeferido os pedidos de

liberdade provisória (fls. 223/226).

Citados, os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 193/196 e 197/205).

Durante audiência de instrução e julgamento, foram colhidos depoimentos das testemunhas, bem como realizado o interrogatório dos réus, conforme mídia anexa aos autos.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal para absolvição dos réus no tocante à imputação da prática do crime de associação criminosa e condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11343/06.

A defesa de MARCELO BRANDÃO LEITE requereu a absolvição do crime de tráfico de drogas, a luz da dicção do artigo 386, III, da legislação adjetiva penal e a absolvição com relação ao delito de associação. Ademais pugnou pela atenuante de confissão e causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. E em caso de condenação que seja substituída por uma restritiva de direito.

A defesa de VICENTE JÚNIOR DA CRUZ requereu a absolvição do réu, na forma do artigo 386, inciso III (por atipicidade da conduta), ou subsidiariamente, na forma do inciso VII (por insuficiência de provas - princípio in dubio pro reo), do Código de Processo Penal. A absolvição do réu em relação ao crime de tráfico de drogas, na forma do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, reconhecendo a tese de inexigibilidade de conduta diversa (coaçoão moral irresistível) prevista ao teor do artigo 22, do Código Penal, ou subsidiariamente na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva. Ademais pugnou pela atenuante de confissão e causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. E em caso de condenação, seja substituída por uma restritiva de direito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta contra Marcelo Brandão Leite e Vicente Júnior da Cruz pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, V, e 35, todos da Lei nº 11.343/06.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Consta na denúncia que no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 18h00min, na Rodovia SP 270, Km 481 leste, nesta comarca de Paraguaçu Paulista, MARCELO BRANDÃO LEITE e VICENTE JÚNIOR DA CRUZ, já qualificados, previamente associados e agindo com unidade de desígnios, transportaram, entre Estados da Federação, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 31 tijolos inteiros e 20 tijolos fracionados de maconha, com massa bruta de 26 quilograma(s), droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo de constatação de fls. 53/55.

Segundo consta, em data anterior ao dia 27 de setembro de 2021, MARCELO e VICENTE associaram-se para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Assim é que, supostamente, no dia do fato, os denunciados transportavam as sobreditas drogas do município de Coronel Sapucaia/MS para o município de São Gonçalo/RJ no veículo Renault/Logan, placas KYS7A68 - São Gonçalo/RJ, com o intuito de comercializá-las, quando foram surpreendidos por policiais militares rodoviários.

Na ocasião, policiais militares rodoviários realizavam fiscalização de rotina na Rodovia SP 270, Km 481, quando se depararam com o veículo supramencionado, conduzido por VICENTE, tendo como passageiro MARCELO, contexto em que lhes deram ordem de parada.

Ao inspecionarem o veículo Renault/Logan, os agentes encontraram 31 tijolos inteiros e 20 tijolos fracionados de maconha, ocultos em seu interior, ocasião em que VICENTE, condutor do veículo, admitiu informalmente aos policiais que a droga havia sido buscada no Estado do Mato Grosso do Sul com destino ao Estado do Rio de Janeiro, revelando a prática do tráfico interestadual.

A natureza e a quantidade significativa da droga, as circunstâncias em que se deram os fatos, além da confissão informal de VICENTE, demonstram que as substâncias

entorpecentes eram destinadas à traficância ilícita.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelos termos de depoimento em solo policial (fls. 09/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelas fotografias juntadas às fls. 36/46, pelo laudo de constatação (fls. 53/55), pelo laudo definitivo (fls. 249/251) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria também é certa e recai sobre os réus.

Senão, vejamos a prova oral colhida em solo policial e em audiência.

Em solo policial, a testemunha Fernando Ferrer relatou que: "Como Policial Militar Rodoviário que é lotado no TOR, estava em serviço de patrulhamento por rodovias deste Município, juntamente com seu colega de farda CB/PM LUIZ FERNANDO, quando pela Rodovia Raposo Tavares, altura do km 481, notaram logo a frente o veículo Renault/Logan, placa Mercosul, ocupado por dois elementos e resolveram pela abordagem. Sem reação a princípio, mas o comportamento dos ocupantes denotavam algo de ilegal, primeiramente o condutor, identificado como Vicente Junior da Cruz afirmou que comprou o auto, mas não transferiu para seu nome. O passageiro, Marcelo Brandão Leite afirmou que o veículo era locado. Resolveram pela revista no auto, tendo no compartimento de bagagens um cilindro de gás GNP vazio, mas tendo uma portinhola que o Depoente abriu e constatou a existência de 31 tabletes da erva tida por maconha bem como 20 pedaços fragmentados da mesma erva. Não havendo como negar, afirmaram que são do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente da Cidade de São Gonçalo, e foram contratados para buscar a e 31 tabletes e condutor afirmou que tinham ido buscar na Cidade de Coronel Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul e entregariam em São Gonçalo mesmo. Que diante da situação o Depoente deu a voz de prisão por tráfico de substância entorpecente, levando a ocorrência até a Base da Polícia Rodoviária e efetuaram revista minuciosa no veículo e autuados, mas nada mais de ilegal foi localizado. Com a apresentação da ocorrência na Delegacia de Polícia, foi mantida a voz de prisão e encaminhada a substância apreendida a exame pericial, restando num peso total de 26 quilos da erva tida por maconha. Foram apreendidos os dois aparelhos celulares dos autuados". (fl. 09) Em juízo, contou que: "Que foi um dos policiais que realizou a abordagem. Que estavam em serviço, abordaram o veículo com placa do Rio de Janeiro com duas pessoas do sexo masculino, e ao conversar com eles, primeiramente o Marcelo disse que havia saído do Rio de Janeiro, São Gonçalo, se não se engana, para ir até Caraapó visitar a tia que estava doente, e que o Vicente era uber e pagaria 5 mil reais há ele por levar para visitar sua tia. Que começaram a fazer questionamento, perguntavam porque a mãe dele também não foi e perceberam que os acusados começaram a ficar incomodados com os questionamentos. Que começaram a fiscalizar o veículo e quando chegou próximo do cilindro de GNV, eles falaram que já havia sido fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal em duas oportunidades, pelo que se lembra, uma em Dourados e outra em Nova Andradina. O sargento bateu no cilindro, percebeu que estava vazio, tiraram as cintas que amarravam o cilindro e ao girar perceberam que a cor do cilindro estava pintada um pouco mais clara, raspou a ponto do metal e saiu massa plástica e depois que tirou visualizaram a droga dentro do cilindro. Que questionaram os réus e estes confessaram que foram até Coronel Sapucaia pegar a droga e levaria até o Rio de Janeiro. Que Marcelo falou que receberia R\$ 10.000,00 para fazer esse serviço, e o Vicente falou que receberia R\$ 5.000,00. Que encontraram aproximadamente 26 quilos de maconha, estava bem fracionada, tinha tabletes inteiros e outros fracionados para preencher os espaços. Que o Vicente contou que foi o Marcelo que levou o cilindro para preencher com droga e depois voltou no carro com o cilindro, mas tinha conhecimento de que estava transportando a droga. Que eles disseram que foram juntos em Coronel Sapucaia buscar a droga, mas em um determinado momento Marcelo levou o cilindro em um local que Vicente não soube informar para inserir a droga. Que não se recorda quantos dias antes os réus foram para cidade buscar a droga. Que os réus falaram que era a primeira vez que haviam ido buscar a droga. Que pelo tempo que trabalha na rodovia é comum que se faça apreensão com essa quantidade de drogas, de 10 quilos até 10 toneladas, nesse trajeto é comum, e também é comum ter motorista de aplicativo. Que Vicente falou que iria receber R\$ 5.000,00, e que a pergunta foi feita a respeito da droga que já havia sido localizada e não mais

sobre o transporte de Uber, mesmo que o valor pago para o transporte de Uber também era R\$ 5.000,00. Que a princípio quando começou a questionar eles ainda não haviam encontrado a droga, e que depois que encontrou a droga falou que eles estavam presos, que tinham o direito de permanecer calado, o direito de advogado. Que é comum encontrar ônibus de transporte de passageiro transportando droga, e taxista só pegou apenas uma vez, e uber é comum, muitas vezes não é uber, mas acaba dizendo que é. Que outra conversa suspeita inicialmente, foi que Marcelo disse que contratou Vicente como Uber para levar até sua tia doente e dormiram 2 dias na casa da tia, o que não é comum de acontecer sendo Uber, a não ser que seja amigo".

Em solo policial, a testemunha Luiz Fernando dos Santos relatou que: "Como Policial Militar Rodoviário que é lotado no TOR, estava em serviço de patrulhamento por rodovias deste Município, juntamente com seu colega de farda CB/PM FERRER, quando pela Rodovia Raposo Tavares, altura do km 481, notaram logo a frente o veículo Renault/Logan, cor prata, placas Mercosul, ocupado por dois elementos e resolveram pela abordagem. Sem reação a princípio, mas o comportamento dos ocupantes denotavam algo de ilegal, primeiramente o condutor, identificado como Vicente Junior da Cruz afirmou que comprou o auto de uma amiga, mas não transferiu para seu nome. O passageiro, Marcelo Brandão Leite afirmou depois que o veículo era locado. Resolveram pela revista no auto, tendo no compartimento de bagagens um cilindro de gás GNV vazio, mas tendo uma portinhola que o Condutor abriu e constatou a existência de 31 tabletes da erva tida por maconha bem como 20 pedaços fragmentados da mesma erva. Não havendo como negar, afirmaram que são do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente da Cidade de São Gonçalo, e foram contratados para buscar os 31 tabletes na Cidade de Coronel Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul e entregariam em São Gonçalo mesmo, sendo que Marcelo receberia dez mil e Vicente cinco mil. Que diante da situação seu colega de farda deu a voz de prisão por trafico de substancia entorpecente, levando a ocorrência até a Base da Polícia Rodoviária e efetuaram revista minuciosa no veículo e autuados, mas nada mais de ilegal foi localizado. Com a apresentação da ocorrência na Delegacia de Polícia, foi mantida a voz de prisão e encaminhada a substancia apreendida a exame pericial, restando num peso total de 26 quilos da erva tida por maconha. Foram apreendidos os dois aparelhos celulares dos autuados. Os autuados mantiveram contato com familiares por meio dos próprios aparelhos. Que os autuados entrevistados com a Delegada afirmaram que só iriam se manifestar em Juízo. Não houve violência na detenção, condução e nem prisão dos autuados". (fl. 10) Em juízo, contou que: "Que estavam em fiscalização no km 481 da Rodovia Raposo Tavares, local pertencente a Paraguaçu Paulista, durante a fiscalização abordaram um veículo logan na cor prata, placas Mercosul, sendo ocupado por Marcelo e Vicente, Vicente estava na condução do veículo. Que durante a fiscalização a equipe notou certo nervosismo com ambos ocupantes, que foi perguntado ao Vicente de quem era o veículo e ele disse que havia comprado de uma amiga recentemente e não havia feito a transferência, já o Marcelo disse o veículo era locado. Durante o nervosismo dos dois e dessa alegação a equipe começou a fazer a vistoria veicular e no porta malas do veículo foi notado um cilindro de gás GNV na cor amarela que estava desativado do veículo. Que a equipe começou a vistoriar o cilindro e encontrou na parte inferior uma portinhola protegida por massa plástica que acondicionava essa quantidade de drogas. Mediante a localização dos entorpecentes, os réus disseram para equipe que saíram de São Gonçalo - Rio de Janeiro, com destino a Coronel Sapucaia- Mato Grosso do Sul, onde pegaram a droga e lavariam para o Rio de Janeiro novamente, que Marcelo receberia R\$ 10.000,00 e o Vicente R\$ 5.000,00, que os dois confirmaram essa versão. Que as drogas estavam em tabletes encaixada em toda a parte interna do cilindro. Que eles disseram quando haviam ido para Mato Grosso do Sul, mas não se recorda quando. Que não se recorda deles mencionarem a cidade de Carapó, e nem nome de terceiros. Que lembra que houve uma conversa no momento da abordagem que Marcelo havia contratado Vicente como uber, mas não se recorda dos detalhes. Que normalmente quando são 2 acusados, eles conversaram separadamente com cada policial, por isso Marcelo ou Vicente pode ter dito algo para outro policial e o declarante não escutou".

Em juízo, a testemunha Carlos Vinicius Lemos de Souza contou que: "conhece Vicente porque ele mora próximo a casa do declarante, não possui relação próxima. Que sabe

que Vicente antes de ser preso era motorista de aplicativo e participava do grupo de motorista. Que com relação ao carro, o declarante já havia alugado esse carro da Sr. Sueli, que ficou 02 meses com esse carro alugado. Que se fizesse um pedido no Uber constaria esse veículo no cadastro do declarante. Que como tem certa relação de proximidade com Sueli, por residirem perto, o declarante pagava cerca de R\$ 500,00 por semana referente ao aluguel do veículo, era um contrato feito mais na confiança, da mesma forma que era com Vicente. Que o declarante foi quem levou Vicente até a Sueli para alugar o carro que antes o declarante usava, pois havia comprado outro. Que quem pagava a prestação do veículo e o seguro era Sueli. Que Vicente sempre foi trabalhador, inclusive ele trabalhava em ótica, e só ingressou na uber porque o movimento ficou muito fraco. Que na época dos fatos o carro não estava cadastrado no nome do declarante mais porque quando passou para Vicente a Sueli pediu para que o declarante tirasse para não dar problema em relação ao seguro dela por conta da diferença de nomes de motoristas. Que Vicente tem cadastro na uber e na 99".

Em juízo, o informante Jhonatan Couto Velasco disse que: "É amigo do réu e ele mora perto de sua residência. Que conhece Vicente como motorista de aplicativo. Que não se recorda há quanto tempo exatamente Vicente começou a trabalhar com isso antes da data dos fatos, acredita que seja em torno de 01 e 02 meses, sabe que tem mais 01 ano. Que o declarante e o Vicente fazem parte do mesmo grupo de motorista, visto que o declarante também trabalha com aplicativo há cerca de 5 anos. Que o declarante ensinou ao réu como utilizar a plataforma. Que em relação ao carro apreendido é um carro de aplicativo e sempre é alugado, o carro pertence a Sueli, que é vizinha da declarante, que inclusive um carro que está no nome dela é o carro que o declarante trabalha, ela alugou. Que nunca soube nada do Vicente, pelo contrário, ele sempre foi trabalhador, que antes de trabalhar no uber, trabalhava em uma ótica, que a esposa da declarante já fez diversos óculos com ele".

Em juízo, o informante Wesley Nascimento declarou que: "É amigo do Marcelo. Pode dizer que Marcelo é muito amigo, que conheceu ele na época que era militar e tinham um amigo em comum. Que saíam muito em casal, pois a mãe do filho do declarante é muito amiga da ex-noiva de Marcelo, e isso já faz 10 anos e continuou. Que conhece a família de Marcelo, a mãe dele. Que Marcelo é bastante conhecido, e depois dessa época do quartel ele trabalhou com a ex-noiva dele na loja de tinta, também trabalhou como uber para ganhar um extra. Sempre foi trabalhador tanto que foi uma surpresa para o declarante".

Em juízo, o informante Rafael Martins declarou que: "É amigo de Marcelo. Que conhece Marcelo há cerca de 8/9 anos. Que o declarante tinha uma barbearia na faculdade e Marcelo foi cortar o cabelo lá e fizeram uma amizade. Que Marcelo sempre foi trabalhador, já foi uber, já foi militar, trabalhou no exercito. Que foi um susto para o declarante. Que Marcelo sempre foi um bom filho, inclusive o padrasto de Marcelo é cliente do declarante e sempre falou muito bem de Marcelo, que sempre foi muito trabalhador e sempre ajudou sua família".

Durante interrogatório policial, o acusado Marcelo Brandão Leite declarou que: "deseja exercer seu direito constitucional de permanecer calado nesta fase inquisitiva e somente se manifestar na fase judicial. Que sua prisão foi levada a conhecimento de seus familiares, inclusive conversou em viva voz". (fl. 11)

Durante interrogatório judicial, contou que: "Que os fatos são verdadeiros. Que realmente saiu de São Gonçalo e foi buscar essa droga em Coronel Sapucaia, que até chegar em Coronel Sapucaia não sabia, mas na volta do trajeto tinha ciência do que estava transportando. Que com relação a associação com Vicente não é verdade. Que morava com os pais no Rio de Janeiro, e os pais sempre foram donos de restaurante/bar, que seu pai na verdade é seu padrasto, mas chama de pai porque criou o declarante desde os 03 anos, e o declarante sempre trabalhou com eles e em determinado momento seus pais começaram a se desentender, já estavam a mais de 20 anos juntos, que um dia ao sair do restaurante sua mãe pediu para ir ao shopping com ela, que foram e chegaram mais tarde naquele dia, e ao chegar na residência seu pai estava bebendo e começou a se alterar com sua mãe, e seus pais se separaram nesse dia, e o restaurante era a única fonte de renda, seu pai saiu de casa e o declarante precisava sustentar a casa e foi onde começou a ficar apertado e pegou

um empréstimo com o agiota no Rio de Janeiro no valor de R\$ 3.000,00 e o declarante falou que em um mês pagaria, porém com o decorrer do tempo não conseguiu pagar essa dívida e o agiota começou a lhe ameaçar, a cercar sua casa e o declarante começou a ficar em desespero, e um dia o agiota marcou um encontro e disse que iria dar um destino para a dívida, no local do encontro o agiota colocou o declarante em seu carro e levou até um favela chamada Salgueiro, e ao chegar nessa favela foi abordado por umas 10/12 pessoas armadas e falou que iria morrer, que lacraram sua mão como se fosse uma algema com fita crepe e lhe colocaram no porta mala do carro e falaram que não iria sair de lá vivo, e o agiota chamou o chefe da reunião e falou que o declarante era a pessoa que estava devendo e não queria pagar e que podia fazer o que quisesse, que o declarante falou que morava no Bairro da Trindade e este chefe ligou para o chefe do bairro, para ver sobre a índole de Marcelo, que esse chefe do seu bairro tomou um susto quando viu o declarante porque lhe conhecia e pediu mais uma chance para que o declarante pudesse pagar e por isso foi liberado. Que a dívida estava em R\$ 5.000,00 contando os juros porque já tinha passado 5 meses. Que este chefe do bairro foi até sua residência e falou que ia ajudar ele a pagar a dívida, mas precisava que o declarante lhe ajudasse também, que tinha uma situação para pegar no Mato Grosso e o declarante devia ir pegar se não iria ter problema com ele. Que estava desesperado procurando emprego para poder pagar isso. Que o declarante conheceu um rapaz de nome Otavio que tinha loja em Fortaleza e através desse rapaz que conheceu o Vicente, esse rapaz estava abrindo uma loja em São Gonçalo, e o declarante estava pedindo emprego em vários lugares, no Facebook, no Instagram e Otavio se proporcionou a lhe dar um emprego porque estava abrindo a loja e já conhecia o declarante. Nesse período Otavio havia deixado seu carro em Fortaleza e trouxe o carro em uma cegonha de transportadora porque veio de avião para o Rio de Janeiro e ele conhecia o Vicente, porque a esposa do Otavio era prima da esposa do Vicente, Vicente sempre fazia corrida para ele e foi assim que conheceu Vicente. Que o declarante não sabia como ia conseguir um carro ou algum Uber para ir buscar essa situação lá no Mato Grosso para o chefe do bairro. Que quando foram buscar o carro, Otavio entrou no galpão para buscar o carro e Vicente ficou do lado de fora conversando com o declarante, e nesta conversa Vicente disse que o movimento do Uber estava fraco, oportunidade na qual o declarante perguntou se Vicente toparia fazer uma viagem de Uber para o Mato Grosso, e Vicente perguntou por quantos dias e o declarante falou que era só visitar uma tia e voltar. Passado alguns dias entrou em contato com Vicente porque havia pego o WhatsApp dele e perguntou qual o preço que Vicente iria cobrar para levar em Mato Grosso do Sul, que no momento Vicente não informou porque queria conversar com a esposa, e passado um tempo mandou mensagem novamente e Vicente disse que iria cobrar R\$ 5.000,00, seria R\$ 2.000,00 da despesa do combustível e R\$ 3.000,00 que o declarante combinou que daria assim que chegasse no Rio. Que assim informou chefe do bairro que achou Uber que levaria ele até o Mato Grosso e que ele precisava apenas do valor do combustível e no dia seguinte o declarante e o Vicente pegaram estrada em direção a Mato Grosso do Sul. Chegando lá o declarante tinha o contato da pessoa que iria estar lhe esperando e essa pessoa lhe mandou a localização de onde estaria, e assim que chegaram no local, que era uma praça foram abordados por 3 pessoas, inclusive esse rapaz que tinha o contato cujo o nome é Alido, a esposa dele que estava grávida e mais um rapaz, que chegaram lá entre 18h/19h, estava anoitecendo, que perguntaram se ele estava com fome. Que essas pessoas colocaram eles no banco de trás e levaram eles. Que essas pessoas falaram que era melhor tirar o carro dessa casa que Vicente e o declarante iam ficar e levar o carro para outra casa, porque os policiais estavam rondando muito ali e por ser placa de fora poderia alarmar a situação, que Vicente achou estranho, mas deu a chave do carro. Que no outro dia uma pessoa conversou com o declarante e perguntou se sabia o que ele havia ido buscar, o declarante negou e a pessoa falou que era maconha, que ia levar uma quantidade de maconha para o Rio de Janeiro para quitar a dívida que o declarante tinha, que a situação que o declarante estava não tinha escolha. Que Vicente viu que tinha algo estranho e perguntou ao declarante o que estava acontecendo e foi aí que explicou toda a situação para Vicente. Que passou um tempo chegou outro rapaz e

deu umas quentinhas para o declarante e para Vicente almoçar, momento em que este começou a conversar com Vicente, relacionado a vida dele, a facebook, instagram, onde mora e foi aí que Vicente sem reação começou a passar algumas informações, e a habilitação do Vicente estava dentro do carro que havia sido levado. Que as pessoas terminaram o serviço no carro, umas 20/21 horas. Que os acusados saíram do Rio na quinta feira, chegaram lá na sexta feira entre 18/19 horas, passou a noite lá, no sábado o serviço no carro ficou pronto entre 20/21 horas e foi liberado para sair apenas pela manhã por volta de umas 04/05 horas. Que as pessoas até lhe ofereceram uma quantidade maior de maconha caso o declarante quisesse mais dinheiro, mas o declarante negou, falou que não queria nada além disso, só queria pagar o que devia para poder se livrar da dívida, que as pessoas falaram que ele era bobo porque mesmo sendo pego com pouca quantidade seria preso do mesmo jeito. Que vieram embora, na Polícia Federal foram parados e revistaram o carro e não conseguiram achar nada, que depois em outro posto policial foram parados novamente e nada foi encontrado, e aqui em Paraguaçu os policiais pararam, novamente, eram 03 policiais, os policiais separaram o declarante e o Vicente e começaram a fazer perguntas na qual o declarante contou a mesma história que havia ido visitar a tia, mas não conseguiu ser verdadeiro onde os policiais viram que tinha algo estranho e resolveram abordar o veículo e na averiguação do veículo conseguiram achar dentro do cilindro de gás a droga. Que está muito arrependido. Quem iria pagar o Vicente era o declarante quando chegasse no Rio de Janeiro. Que o declarante não iria receber nada que o serviço era o valor da dívida. Que as pessoas iam pagar o resto do uber, os R\$ 3.000,00 que faltava, já estava conversado. Que contou para Vicente que estava transportando maconha depois que passou pela Polícia Federal. Que a todo momento pensava em ir na polícia e desistir mas estava sofrendo ameaças, não poderia fazer isso. Que foi a primeira vez que fez isso. Que mora em São Gonçalo desde os 4 anos de idade e onde mora é um dos piores lugares que existe no Rio de Janeiro, várias áreas dominadas por facções e acabam ficando na mão delas. Que está muito arrependido, nunca imaginou passar por isso, que a penitenciária é muito distante e mal vê sua mãe e sua esposa".

Durante interrogatório policial, o acusado Vicente Junior da Cruz declarou que:

"que deseja exercer seu direito constitucional de permanecer calado nesta fase inquisitiva e somente se manifestar em juízo. Que sua prisão foi levada a conhecimento de seus familiares, inclusive conversou em viva voz". (fl. 11)

Durante interrogatório judicial, contou que: "Que os fatos não são verdadeiros. Que nunca disse que o carro lhe pertencia, o carro é alugado da Sr. Sueli, o declarante não tem carro. Que ficou sabendo que estava transportando droga no meio do caminho. Que não conhecia o Marcelo, conheceu através de um amigo em comum chamado Otavio que tem uma loja de multimarcas, que o Otavio sempre que precisa de uber contrata o declarante, e o Otavio precisava buscar o carro no porto em São Cristóvão, que o declarante já estava com um corrida marcada de 52 reais e cancelou essa corrida para ajudar Otavio e foi levar ele até São Cristóvão. Que quando chegou na loja, Marcelo também entrou no carro e Otavio lhe apresentou e quando chegaram no porto para pegar o carro, o declarante e o Marcelo ficaram para fora porque somente o Otavio podia entrar e foi aí que começou a conversar com Marcelo e Marcelo lhe perguntou se poderia viajar para Mato Grosso por 3 dias e o declarante falou que precisava ver com sua esposa pois não faz nada sem conversar com ela e passou o número para Marcelo. Que passado 2/3 semanas o Marcelo mandou mensagem perguntando se poderia levar ele no Mato Grosso na casa da tia que estava com câncer e o declarante já havia conversado com sua esposa e falou que iria, que demorou uns 10 minutos para passar o valor, que no aplicativo sugeria R\$ 4.800,00, e o declarante cobrou R\$ 5.000,00 para levar Marcelo e ficar 3 dias lá, e o declarante também iria dormir na casa da tia dele. Que foi levar Marcelo, quando chegaram lá o GPS deixou em uma praça, foram abordados por 3 pessoas, saiu do banco do motorista, foi para o banco de trás e levaram os dois até um casa que não tinha garagem, tinha apenas um quarto e um banheiro, este indivíduo que abordou o declarante perguntou se ele estava com fome e o declarante disse que sim, porque estava dirigindo a bastante tempo e ele trouxe comida para o declarante e para o Marcelo, que o indivíduo deixou o carro e levou a chave para o declarante. Que o declarante perguntou para

Marcelo o que estava acontecendo, e ele pediu desculpa, falou que estava devendo para um agiota no Rio e por isso fez o declarante trazer ele até aqui. Que o indivíduo pegou o RG, o CEP da residência e o facebook da esposa do declarante. Que quando pegou o carro de volta nem olhou o carro, só queria vir embora. Que pararam na Polícia Federal e o policial olhou o carro todo e como o declarante não sabia o que tinha no carro ficou com muito medo. Que depois que passaram da Polícia Federal, Marcelo contou o que tinha no carro, que não podia abandonar o carro porque as pessoas estavam com seu documento e se fizesse isso elas iriam atrás do declarante. Que é inocente, nunca usou drogas, trabalha desde os 14 anos, tem 22 anos de carteira assinada. Que em momento algum falou para os policiais que receberia R\$ 5.000,00 pelo transporte das drogas, falou que iria receber pelo trabalho de uber que estava fazendo e não pela droga. Que não contou essa história no momento em que foi abordado porque não podia contar porque ficou com medo. Que nos 03 dias que ficou na residência nenhum dia teve acesso ao veículo, não podia sair de dentro da casa que a alimentação chegava até eles. Que Marcelo contou que tinha alguma coisa no cilindro, mas não contou o que era, só foi contar depois que passou da Polícia Federal. Que antes de ser preso estava com esse carro há 1 ano e 6 meses, e o contrato com a Sueli era verbal, porque a Sueli conhece o declarante desde criança, o uber era para complementar a ganho de sua loja que estava fraco na pandemia. Que estava no lugar errado na hora errada. Que pagava 500 reais no aluguel no veículo, pagava para o filho da Sueli o Jonathan, e tem isso no celular. Que Jonathan filho da Sueli é policial da CORE. Que o carro é novo 2017/2018, e o carro é limpo, nunca foi usado para isso, é um carro que usava para passear com a família, para trabalhar. Que se soubesse que se tratava de drogas jamais faria esse serviço. Que as pessoas na residência falaram que o material tinha que chegar no Rio de Janeiro, e se não chegasse o declarante e o Marcelo iriam ter que prestar contas, que sua esposa está na casa de sua sogra já tem 06 meses porque está com medo de ficar na residência. Que quando estava na residência escutou o nome Alido, que foi quem levou o carro para a garagem e lhe entregou a chave do carro".
Pois bem.

- Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

Os elementos coligidos durante a instrução processual mostram-se suficientemente seguros para a expedição do decreto condenatório em desfavor dos réus no tocante ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Os policiais apresentaram versões uníssonas e harmônicas tanto na fase policial quanto em juízo no tocante à prática do tráfico ilícito de entorpecentes pelos réus.

Contaram que abordaram o veículo na rodovia e começaram a fazer questionamento para os dois ocupantes, Marcelo e Vicente, no qual notou-se que começaram a ficar incomodados, demonstrando certo nervosismo e incoerência na conversa. Por esse motivo, começaram a realizar revista no veículo, quando se depararam com um cilindro GNV, vazio, amarrado, no qual perceberam que havia uma parte que estava pintado de cor diferente, e dentro deste cilindro foi constatado aproximadamente 26 quilos de maconha, com tabletes inteiros e outros fracionados para preencher os espaços.

Contaram ainda que os réus afirmaram que são do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente da Cidade de São Gonçalo, e foram contratados para buscar a referida droga na Cidade de Coronel Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul e entregariam em São Gonçalo mesmo. E que Marcelo falou que receberia R\$ 10.000,00 e Vicente declarou que receberia a quantia de R\$ 5.000,00, ambos para o serviço do tráfico de drogas.

É cediço que a palavra dos policiais, quando coerentes com os elementos trazidos aos autos, tal como na hipótese dos autos, é apta a comprovar a prática da infração penal.

Nesse sentido:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimentos de policiais - Admissibilidade - Inexistência de suspeição e contradição - Hipótese em que os testemunhos são harmoniosos, claros e precisos - Recurso não provido. Os depoimentos de policiais

que se apresentarem harmoniosos, claros e precisos não podem sofrer desmerecimento como prova criminal". (Apelação Criminal n. 173.078-3 - Guarujá - Relator: FRANCO DE GODOI- CCRIM 3 - V.U. - 12.12.94)

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello.)

Não bastasse isso, durante o interrogatório policial e judicial, o acusado MARCELO confessou o transporte interestadual das drogas. MARCELO saiu de São Gonçalo e foi buscar essa droga em Coronel Sapucaia, e retornaria para São Gonçalo.

Por sua vez, VICENTE confessou que teve ciência do transporte da droga apenas no meio do caminho. Alegando que foi contrato apenas para o serviço de uber e não sabia o que estava acontecendo em sua volta até o momento que MARCELO lhe contou. Ocorre que VICENTE em depoimento judicial contou detalhadamente como os fatos ocorreram, inicialmente contou que não era proprietário do veículo e sim a Sra. Sueli, na qual alugava para que realizasse seu serviço de uber, e que o pagamento do aluguel do referido veículo era feito para o filho da Sra. Sueli, chamado Jonathan que é policial da CORE. E ainda cotou que conheceu Marcelo, por conta de um amigo em comum, chamado Otavio, na qual sempre contratava seus serviços de uber. Nota-se que VICENTE em seu depoimento citou 03 nomes que seriam peças fundamentais para comprovar sua tese afirmativa, visto que nesse caso, o ônus recai sobre a defesa, porém, isso não ocorreu, tendo em vista que nenhum desses nomes foram arrolados como testemunhas para comprovar os fatos alegados pelo réu. A alegação de coação moral irresistível suscitada pela defesa de VICENTE igualmente não deve prosperar. A mera alegação, destituída de qualquer elemento concreto, não é suficiente para demonstrar a situação invencível. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - INOCORRÊNCIA. - Para o reconhecimento da coação moral irresistível, é indispensável a demonstração da ocorrência de situação invencível, não bastando a mera alegação do acusado. (TJ-MG - APR: 10702180962384001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020)

Levando em consideração os critérios estabelecidos no artigo 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, não há qualquer dúvida de que a droga localizada seria destinada ao comércio clandestino de entorpecentes. Isso porque foram localizados 51 tijolos de maconha, sendo 31 tijolos inteiros e 20 tijolos fracionados, totalizando 26 kg de maconha.

Urge mencionar que é "desnecessário que o agente seja flagrado em situação de mercancia para que se configure o tráfico - Quantidade e variedade de drogas, local da abordagem e demais circunstâncias que levam à conclusão de que os entorpecentes seriam destinados ao consumo de terceiros"- Apelação 0057305-71.2012.8.26.0114, Rel. Des. Amado de Faria, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 22/10/2013". No mais, "o fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, 'caput', da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ('importar', 'exportar', 'remeter', 'preparar', 'produzir, fabricar, 'adquirir', 'vender', 'expor à venda', 'oferecer', 'ter em depósito', 'transportar', 'trazer consigo', 'guardar', 'prescrever', 'ministrar', 'entregar a consumo' ou 'fornecer drogas'), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em

atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que gratuitamente" (...) - TJSP, Apelação 0001686-11.2011.8.26.0400, Rel. Des. AIRTON VIEIRA, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 10/10/2017.

Diante desse cenário, certo é que os elementos coligidos são robustos para sustentar um decreto condenatório, de forma a responsabilizar os réus pelo delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei 11343/2006

Entendo que não ficou demonstrada a prática do crime de associação para o tráfico de drogas descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, eis que não atestada a estabilidade e permanência entre os réus. Aliás, esta é a diferença entre o crime mencionado e o simples concurso de agentes. Nesse sentido, é a jurisprudência remansosa do C. STJ e do STF, senão vejamos:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MERA ATUAÇÃO EM COMUM NA PRÁTICA DE UM DELITO. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. ATIPICIDADE RECONHECIDA. MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA NOVA LEI DE TÓXICOS, FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE, EM TESE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. Paciente condenada, em sede de apelação, como incurso no arts. 33 e 35, c.c. 40, inciso III, todos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, porque, no dia 23 de outubro de 2008, foi presa em flagrante delito por pagar à corré para entregar uma porção de maconha, com massa de 78,67 g, a seu irmão detento, dentro do Presídio. 2. O acórdão impugnado entendeu pela desnecessidade do ânimo associativo permanente, reconhecendo que a associação para a prática de um crime seria suficiente para condenar a acusada como incurso no art. 35 da Lei n.º 11.343/06. Entretanto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para configuração do tipo de associação para o tráfico, necessário estabilidade e permanência na associação criminosa. Atipicidade reconhecida. 3. Reconhecida a atipicidade da conduta de associação eventual para o tráfico de drogas, o édito condenatório perdeu seu único argumento para negar à Paciente a causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que, considerou o acórdão impetrado que a condenada, ora Paciente, não preenche os requisitos legais para a concessão da benesse por integrar associação criminosa. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 5. Afastado o óbice previsto na Lei de Drogas, pela Resolução n.º 05/2012, do Senado Federal, deve o Juízo competente analisar se o condenado preenche ou não os requisitos para a obtenção da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para cassar a condenação no tocante ao crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e determinar que o Eg. Tribunal de Justiça a quo proceda ao exame do preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão da minorante no prevista no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, do regime adequado de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Por se encontrar em idêntica situação processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos do julgado à corré LUCELINE DA SILVA PAIVA.(STJ - HC: 248844 GO 2012/0148550-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, j. em: 21/05/2013, T5 - QUINTA TURMA)

Por isso, impõe-se a absolvição no tocante à imputação da prática do crime descrito no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Pois bem.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

a) RÉU MARCELO BRANDÃO LEITE

Na primeira fase da dosimetria da pena, respeitando o sistema trifásico e atento

aos critérios estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade de droga apreendida (51 tijolos - 26 kg) fixo a pena-base em 05 anos e 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante de confissão, contudo, atendendo ao teor da Súmula nº 231 do E. STJ, fixo a pena intermediária no mínimo legal, isto é, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, entendo que está presente a causa de diminuição estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que não existem elementos concretos que indiquem que o acusado se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, além de possuir bons antecedentes e ser primário. Por essa razão, diminuo a pena do acusado em 1/6, fixando como a pena em 04 anos e 02 meses de reclusão e 415 dias-multa. Saliento que é plenamente possível que, no curso da dosimetria da pena, do cotejo da prova dos autos, o juízo reconheça a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ainda que de ofício. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). (HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021). - Desse modo, constatei que o fundamento utilizado pela Corte distrital para denegar a redutora do tráfico privilegiado ao paciente, foi a quantidade de droga apreendida - 15.799,30 gramas de maconha (e-STJ, fl. 24) -, associada ao fato de ele possuir ação penal em curso pela prática de idêntico delito; Todavia, o fato de o agente possuir uma ação penal em curso não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tampouco a quantidade de entorpecentes apreendidos, dissociada de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa. - Assim, fica mantida a incidência da minorante pelo tráfico privilegiado ao paciente, com a extensão dos efeitos da decisão ao corréu, tendo em vista a similitude das situações fáticas e jurídicas entre eles, nos termos do art. 580, do CPP. - Agravo regimental não provido. (Superior Tribunal de Justiça. 5ª Turma. AgRg no HC 717364 / DF. j. em 15/03/2022)

Ainda, vislumbro a presença da causa de aumento descrita no artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, eis que, conforme elementos coligidos nos autos, a droga foi transportada do Estado de Mato Grosso do Sul para o Estado de São Paulo ainda com destino final que seria no Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual majoro a pena intermediária em 1/6, fixando definitivamente a pena em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, eis que não ficou demonstrado que o réu detém capacidade econômico-financeira para suportar exação maior.

Tendo em vista o quantum da pena aplicada, as circunstâncias concretas do fato, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal. A gravidade concreta dos fatos

revela que nenhum outro regime prisional é adequado ao caso.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do CP) e a suspensão condicional (artigo 77 do CP), em razão da pena fixada.

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a detração e a progressão de regime de cumprimento da pena são matérias afetas à execução criminal, não dependendo só de critérios objetivos, mas, principalmente, de critérios subjetivos, referentes ao comportamento do acusado no estabelecimento prisional, os quais só podem ser efetivamente verificados quando da execução.

b) VICENTE JÚNIOR DA CRUZ

Na primeira fase da dosimetria da pena, respeitando o sistema trifásico e atento aos critérios estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade de droga apreendida (51 tijolos - 26 kg) fixo a pena-base em 05 anos e 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante de confissão, contudo, atendendo ao teor da Súmula nº 231 do E. STJ, fixo a pena intermediária no mínimo legal, isto é, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, de ofício, entendo que está presente a causa de diminuição estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que não existem elementos concretos que indiquem que o acusado se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, além de possuir bons antecedentes e ser primário. Por essa razão, diminuo a pena do réu em 1/6, fixando como a pena em 04 anos e 02 meses de reclusão e 415 dias-multa. Ainda, vislumbro a presença da causa de aumento descrita no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, eis que, conforme elementos coligidos nos autos, a droga foi transportada do Estado de Mato Grosso do Sul para o Estado de São Paulo ainda com destino final que seria no Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual majoro a pena intermediária em 1/6, fixando definitivamente a pena em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa. Fixo o valor de cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, eis que não ficou demonstrado que o réu detém capacidade econômico-financeira para suportar exação maior.

Tendo em vista o quantum da pena aplicada, as circunstâncias concretas do fato, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal. A gravidade concreta dos fatos revela que nenhum outro regime prisional é adequado ao caso.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do CP) e a suspensão condicional (artigo 77 do CP) em razão da pena fixada.

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a detração e a progressão de regime de cumprimento da pena são matérias afetas à execução criminal, não dependendo só de critérios objetivos, mas, principalmente, de critérios subjetivos, referentes ao comportamento do acusado no estabelecimento prisional, os quais só podem ser efetivamente verificados quando da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

I) ABSOLVER os acusados MARCELO BRANDÃO LEITE e VICENTE JÚNIOR DA CRUZ, qualificados nos autos, da imputação da prática do crime descrito no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2005, o que faço com fulcro